

1502849-65.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO DIEGO PAIXÃO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

RICARDO DIEGO PAIXÃO foi denunciado por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 01 de dezembro de 2021, por volta das 09h30min, na Rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Maua - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502849-65.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502849-65.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO DIEGO PAIXÃO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

RICARDO DIEGO PAIXÃO foi denunciado por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 01 de dezembro de 2021, por volta das 09h30min, na Rua Fernando Colombo, 143 Viela Comunicante - Jardim Salgueiro, nesta cidade de Mauá, o denunciado expunha à venda e vendia, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 09-10), laudo de constatação (fls. 12-4), imagens (fls. 15-6) e exame toxicológico (fls. 65-7).

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação. Testemunhas arroladas pelas partes devidamente inquiridas. Por fim, o réu foi interrogado.

Em memoriais, pleiteia o Ministério Público a procedência da ação nos termos da denúncia, enquanto a Defesa requer, em preliminar, a instauração de incidente de dependência toxicológica. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, ao menos, a aplicação da pena nos patamares mínimos, com o reconhecimento da confissão, e a fixação de regime penitenciário inicial brando.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

A preliminar arguida pela Defesa não merece acolhimento.

Diante da ausência de mínimos indícios de que o acusado estivesse eventualmente desprovido da capacidade de entendimento e autodeterminação no momento dos fatos e considerando-se que a condição de dependente químico não afasta, em absoluto, a possibilidade da prática do comércio ilícito de entorpecentes, verifica-se absolutamente irrelevante e impertinente a instauração de incidente de dependência toxicológica formulada pela Defesa.

Neste sentido o e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06). Preliminar inconsistente. Desnecessidade do exame de dependência toxicológica, diante de sua irrelevância para a caracterização do delito. Mérito. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade da droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Desclassificação para porte de entorpecentes para uso próprio. Impossibilidade. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso. Inaplicabilidade do art. 33, § 4º. Impossibilidade de redução da pecuniária. Regime inicial fechado único possível. Inviabilidade de substituição da corporal por penas alternativas. Apelo em liberdade prejudicado, já que analisado à altura do julgamento. Apelo improvido, rejeitada a preliminar." (AP nº 0001912-86.2015.8.26.0493, Desembargador Relator: Luis Soares de Mello, j. 29.11.16).

Nesse contexto, revelando-se meramente protelatório, afasta-se o pedido, nos termos do parágrafo 1º do art. 400 do Código de Processo Penal. Destaca-se precedentes neste sentido:

"Sabe-se que o magistrado, autoridade que preside a relação processual, pode indeferir a produção das provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (artigo 400, par. 1º, do Código de Processo Penal). E, desde que o faça de forma fundamentada, tal circunstância não traduz qualquer cercamento de defesa" (STF, HC nº 106.734, rel. Min. Luiz Fux; HC nº 106.734, rel. Min. Ricardo Lewandowski, HC nº 108.961, rel. Min. Dias Toffoli; Al nº 794.090, rel. Min. Gilmar Mendes)

"Com efeito, o juiz, por ser o destinatário da prova e estar em contato direto com a causa, detém certa discricionariedade na avaliação da necessidade da prova para a formação de seu convencimento, conquanto que delibere fundamentadamente" (STJ, HC nº 466.115, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, AgRg no RHC nº 31.239, rel. Min. Marco

Aurélio Belizze).

No mérito, a acusação procede.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 06-8), auto de exibição e apreensão (fls. 09-10), laudo de constatação (fls. 12-4), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 65-7) e prova oral colhida.

Comprovou-se a autoria.

O réu, em solo policial (fl.05) e em juízo (mídia digital), manifestou-se.

Os policiais militares, na fase administrativa, historiaram que, com o fim de coibir o tráfico de drogas, observaram o local dos fatos, ponto conhecido pela frequente mercancia de drogas, por aproximadamente dez minutos. Com o uso de binóculos, viram que, por três vezes, o réu recebia algo de usuários de drogas, guardava em um bolso de suas vestes, retirava algo de uma pequena bolsa clara que trazia em suas mãos e entregava a droga aos usuários, que saíam apressadamente do local. Feita a abordagem, o acusado disse que estava no local para adquirir dinheiro para comprar drogas para seu consumo e ficou no lugar do traficante, pelo valor de R\$ 5,00, enquanto ele iria ao banheiro. Na referida bolsa foram encontrados 18 invólucros de maconha, 14 papелotes de cocaína e 12 microtubos de crack, além da quantia de R\$ 52,00.

Em juízo, o policial Adilço reiterou a sua versão. Afirmou que o local é ponto de venda de entorpecentes. Viram o réu atender duas ou três pessoas, que pegava alguma coisa na bolsa e alguma coisa das pessoas. Feita a abordagem, na pochete que estava com o acusado havia maconha, cocaína, crack e uma quantia aproximada de R\$50,00. O réu disse que estava no local para vender entorpecentes, mas que não era o traficante. Afirmou que o acusado não estava tão alterado, tanto que conversou com a equipe e explicou o que estava fazendo (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

A quantidade de droga encontrada e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a variedade e a forma em que era transportada, o local da abordagem, além do dinheiro localizado com o acusado, trazem elementos suficientes de que ele tinha a droga para entrega a terceiros.

Dessa forma, entendo que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado. Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no patamar mínimo, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda etapa, em razão da reincidência específica (cert fl.40 -processo 614-44.2017), aumento a pena do réu em 1/3, perfazendo 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa. A reincidência específica justifica referida fração de aumento, maior o desvalor da conduta.

Neste sentido, precedente do e. Superior Tribunal de Justiça:

"A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)" (HC nº 257.571/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18/02/2014).

Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, em plena traficância, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos. Não fosse suficiente, o presente decisum sequer referiu-se ao interrogatório do réu, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recruto de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobejaria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessório para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a principio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que

confissão espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não dá para conviver; ou confissão voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça”.

Na mesma direção, precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.N.

A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Estabiliza-se, assim, a sanção em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa.

O réu, reincidente específico, deverá iniciar o cumprimento da pena sob regime penitenciário fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal. Pelo mesmo motivo, não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, insuficiente para prevenção e reprovação da conduta. A pena pecuniária foi fixada pelos mesmos critérios, e o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR o réu RICARDO DIEGO PAIXÃO, qualificado nos autos, a cumprir pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar 666 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Denego ao condenado o direito de recorrer em liberdade, mantidas as condições da custódia cautelar.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, determino a destruição da contraprova das drogas e do objeto apreendido, bem como a perda dos valores apreendidos em favor do Funad, eis que comprovadamente obtidos com a narcotraficância, nos termos dos arts. 63 e 72 da Lei n.º 11.343/2006.

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella -Juiz de Direito

(assinado eletronicamente)

Maua, 07 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA